

1500148-62.2020.8.26.0542
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: DANIELLE MARTINS CARDOSO
Comarca: Osasco
Foro: Foro de Osasco
Vara: 3ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 15/06/2022
... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
DIEGO PEREIRA DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DANIELLE MARTINS CARDOSO

Vistos.

DIEGO PEREIRA DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06, porque no dia 17 de janeiro de 2020, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Osasco
Foro de Osasco
3ª Vara Criminal
Avenida das Flores, 703, Osasco - SP - cep 06110-100

1500148-62.2020.8.26.0542 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:
1500148-62.2020.8.26.0542
Classe - Assunto
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
DIEGO PEREIRA DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DANIELLE MARTINS CARDOSO

Vistos.

DIEGO PEREIRA DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06, porque no dia 17 de janeiro de 2020, por volta das 14h15, na Rua Bendito Alves Monteiro, 01, viela, Castelo Branco, nesta cidade e Comarca, agindo de comum acordo e com identidade de desígnios com o adolescente infrator Denilson da Silva Estevam, traziam consigo / guardavam / tinham em depósito, para fins de tráfico, a) 41 (quarenta e um) invólucros plásticos fechados por pressão (tipo "zip") contendo Tetrahydrocannabinol (THC) ("maconha"), com peso líquido total de 138g (cento e

trinta e oito gramas); b) 389 (trezentos e oitenta e nove) invólucros plásticos, fechados por pressão (tipo "zip") e do tipo "filme", contendo Tetrahydrocannabinol (THC) ("maconha"), com peso líquido total de 1.075,23g (um mil e setenta e cinco gramas e vinte e três centigramas); e c) 31 (trinta e um) invólucros plásticos fechados por pressão (tipo "zip") contendo cocaína na forma de "crack", com peso líquido total de 2,93g (dois gramas e noventa e três centigramas), substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão a fls. 06, laudo de constatação a fls. 40/43 e laudo de exame químico-toxicológico a fls. 198/200.

Denúncia recebida em 3 de fevereiro de 2020 (fls. 92).

Réu citado (fls. 122). Resposta apresentada (fls. 126/135).

Antecedentes criminais e laudos periciais juntados.

Durante a instrução processual foram ouvidas duas testemunhas arroladas pelas partes e uma testemunha do juízo. Ao final o réu foi interrogado.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do acusado nos termos da denúncia (fls. 242/254).

A Defesa pugnou pela absolvição por insuficiência probatória e nulidade da prova. De forma subsidiária, pleiteou penas mínimas e regime menos gravoso (fls. 259/275).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A acusação não procede, uma vez que o conjunto probatório não é concludente quanto à autoria e prática do ilícito.

Em juízo, os policiais narraram que flagraram um adolescente com um estojo contendo quinze reais e 41 porções de maconha. Em conversa informal, o menor teria apontado o barraco do réu como o local onde existiam mais drogas. Se deslocaram com o adolescente até o barraco, onde foram recebidos pelo réu. Disseram que no interior da residência do acusado avistaram unidades de maconha em cima da sua cama. Segundo os depoentes, uma mochila preta e azul foi encontrada na parte externa do barraco, nos fundos, em um matagal. Não presenciaram o réu com a mochila ou dispensando o objeto. Disseram que o réu teria confessado a circunstância. Nessa mochila encontraram grande quantidade de drogas (360 porções de maconha, 31 pedras de crack). Os policiais aduziram que o réu estava sozinho e não havia bebê no imóvel. O primeiro policial ouvido, que informou ter lido seus apontamentos antes da audiência, disse que estavam somente em dois policiais, enquanto o segundo policial afirmou a chegada do apoio.

A esposa do réu, ouvida como testemunha do juízo, disse que estava com o acusado no local quando chegaram os policiais, alguns fardados, outros sem uniforme. Um dos policiais trazia nas costas uma mochila preta. Não existiam drogas no local. A testemunha disse que estavam em casa porque ela se encontrava de resguardo. Havia um bebê no imóvel. Contou que o réu foi levado para a delegacia.

O réu negou a acusação e apresentou versão própria. Aduziu que estava em casa com a esposa, que se encontrava de resguardo, quando a polícia lá chegou. Foi acusado em razão dos seus antecedentes. Disse que não usa drogas e que não existiam entorpecentes no local. Possui três filhos e atualmente está trabalhando sem registro.

Trata-se de acusação de tráfico cuja circunstância flagrancial (ausência de posse direta das drogas) necessita de prova robusta e indene de dúvidas, sendo possível a produção de prova técnica e objetiva das circunstâncias extraordinárias do flagrante. Mas isso não ocorreu.

A prova se limitou à apreensão dos entorpecentes descritos na denúncia e aos depoimentos dos policiais, sem qualquer atividade investigativa quanto ao tráfico de entorpecentes.

A mochila contendo as porções de drogas descritas na denúncia foi encontrada na comunidade, na área externa da moradia, de livre acesso a qualquer um. Os policiais não presenciaram a dispensa da sacola e também não fotografaram o local. Inexistem nos autos prova da POSSE da mochila ou mesmo da PROPRIEDADE das drogas que estavam nela, não sendo possível a condenação do acusado porque possui antecedentes e porque eventualmente a mochila estava próxima a sua residência.

Ademais, os relatos e a delação do menor envolvido no ilícito são acusações parciais e suspeitas, e não podem, de forma isolada, alicerçar condenação segura.

Deve o julgador analisar as provas produzidas nos autos, sem presunções ou julgamento antecipado. Se o interesse do réu é se ver livre da acusação, os policiais depõem no intuito de legitimar seus atos e justificar as prisões e diligências realizadas. Ou seja, nunca existirão relatos absolutamente imparciais. A prova acusatória, portanto, há que se mostrar robusta, harmônica e sem contradições, o que não ocorreu no presente caso. Portanto, em que pese os elementos indiciários tenham sido suficientes para o início do processo, as provas produzidas durante a instrução são insuficientes para condenação.

Nesse sentido:

“Para que se reconheça a existência de tráfico ou comércio de drogas, é mister prova absolutamente segura. No caso de dúvida em se saber se o réu é traficante ou usuário, deve subsistir a segunda hipótese, como solução benéfica do in dubio pro reo” (TJSP – AC 133.383-3 – Rel. Egidio de Carvalho – JTJ 140/276).

“Sem embargo da grande quantidade da erva apreendida, havendo peculiaridades que tornam plausíveis as afirmações dos réus de que não pretendiam passar adiante a droga, manda a prudência sejam eles responsabilizados como usuários e não como traficantes. A prova do tráfico há de ser complementada pela acusação; não bastando para sua afirmação a única circunstância de ser grande a quantidade da substância apreendida” (TACRIM-SP – AC – Rel. Tomaz Rodrigues – JUTACRIM 58/339 – grifamos).

Recorro, também, às lições de Guilherme de Souza Nucci:

“Se a prática de uma infração penal é, sem dúvida, um mal à sociedade, mal maior é a busca de um culpado, sem qualquer cuidado e infringindo direitos fundamentais do homem. O Estado não pode ser tão mesquinho e delinquente quanto o indivíduo possa ser, de modo que condenações injustas gerem mais insegurança do que o próprio cometimento do crime. O direito à prova surge vigoroso nesse quadro, porquanto é inerente à defesa, indispensável esteio do Estado de Direito. Logo, cabe a cada magistrado cuidadosamente verificar como está formando sua convicção para que sua imparcialidade, como homem e como representante do Estado, seja o mais próxima possível do ideal”.

Outrossim, verifica-se que as provas derivam da delação do menor e do ingresso no domicílio do acusado, sem qualquer autorização judicial nesse sentido.

A atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal

Federal estabelece que somente é legítimo o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial quando amparado em fundadas razões, nos termos do artigo 240, § 1º, do Código de Processo Penal, que devem ser evidenciadas devidamente pelas circunstâncias do caso concreto. Sobre a fundada suspeita, o voto do Ministro Gilmar Mendes, relator do Recurso Extraordinário 603.616/R0, julgado em 5 de novembro de 2015, esclarece que:

"(...) provas ilícitas, informações de inteligência policial - denúncias anônimas, afirmações de "informantes policiais" (pessoas ligadas ao crime que repassam informações aos policiais, mediante compromisso de não serem identificadas), por exemplo - e, em geral, elementos que não têm força probatória em juízo não servem para demonstrar a justa causa."

Nesse mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 12G (DOZE GRAMAS) DE COCAÍNA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INGRESSO POLICIAL APOIADO EM DENÚNCIA ANÔNIMA E EM ATITUDE SUSPEITA DOS ACUSADOS NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO HC N. 598.051/SP. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Tendo como referência o recente entendimento firmado por esta Corte, nos autos do HC n. 598.051/SP, o ingresso policial forçado em domicílio, resultando na apreensão de material apto a configurar o crime de tráfico de drogas - 12g (doze gramas) de cocaína -, quando apoiado em mera denúncia anônima e no fato de que os policiais, de fora, avistaram os acusados no interior da casa manipulando material, não traz contexto fático que justifica a dispensa de investigações prévias ou do mandado judicial para a entrada dos agentes públicos na residência, acarretando a nulidade da diligência policial, como no caso dos autos. 2. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no RECURSO ESPECIAL nº 1.865.363 - SP - 6ª Turma - Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO - j. 22.06.2021). - grifei.

Ademais, ainda que se desconsidere a questão da denúncia anônima, resta a questão da anuência do acusado para o ingresso domiciliar.

A Corte Superior, no recente julgamento do Habeas Corpus nº 598.051/SP estabeleceu que não basta a prova oral, produzida pelos agentes estatais, a demonstrar que o morador autorizou a entrada da força policial em sua casa, sob pena de se ter prova ilícita.

"A prova da legalidade e da voluntariedade do consentimento para o ingresso na residência do suspeito incumbe, em caso de dúvida, ao Estado, e deve ser feita com declaração assinada pela pessoa que autorizou o ingresso domiciliar, indicando-se, sempre que possível, testemunhas do ato. Em todo caso, a operação deve ser registrada em áudio-vídeo e preservada tal prova enquanto durar o processo. 5. A violação a essas regras e condições legais e constitucionais para o ingresso no domicílio alheio resulta na ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida, bem como das demais provas que dela decorrerem em relação de causalidade, sem prejuízo de eventual responsabilização penal do(s) agente(s) público(s) que tenha(m) realizado a diligência" (Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus 598.051/SP.Relator: Ministro Rogério Schietti Cruz. Julgamento: 2 de março de 2021).

Acontece que a acusação não trouxe provas seguras de anuência do acusado. A simples afirmação dos policiais de que o réu teria assentido com a entrada não é suficiente, sendo necessários outros elementos de prova, o que não ocorreu nos autos.

Por todo o exposto, imperioso concluir que a violação do domicílio - pela ausência de ordem judicial ou de demonstração incontestada de anuência do réu para o ingresso na residência - implica no reconhecimento da ilicitude de toda a prova produzida

pela acusação, porque a inviolabilidade do domicílio é garantia constitucional e direito fundamental do indivíduo, não havendo outra solução que não a absolvição do acusado.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação penal para ABSOLVER DIEGO PEREIRA DA SILVA, qualificado nos autos, da acusação do crime previsto no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Expeça-se o necessário.

Autorizo a incineração da droga apreendida, nos termos dos artigos 32 e 72 da Lei nº 11.343/2006 e regulamentações a respeito.

P. R. I. C.

Osasco, 26 de maio de 2022.